

1501149-60.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA CASTRO ANDRADE SILVA

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... ocorrência para coibir a prática de tráfico e furtos quando viu uma bicicleta no contrafluxo conduzida pelo acusado, que já é conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico e furto. Disse que, ao ser avistado pelos policiais, o acusado acelerou a bicicleta e só foi abordado a cerca de 800 metros. Na busca pessoal, encontraram droga na blusa do acusado, no bolso, e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

1ª Vara

Av. Monsenhor Ângelo Angioni, nº 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501149-60.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501149-60.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185341/2022 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 26028551 -

DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2185341 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO

Autor:

Justiça Pública

Réu

WILLIAM PEIXOTO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE

WILLIAM PEIXOTO DA SILVA (fl. 35) foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (fls. 76/79).

Isso porque, segundo consta, em 08 de julho de 2022, às 21h, no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua 15 de Novembro, centro, nesta cidade e comarca de José Bonifácio-SP, o acusado praticou o ato de trazer consigo para entrega a consumo de terceiros, 18 invólucros do entorpecente cocaína, na forma de crack, pesando 3,19 gramas; 03 invólucros contendo maconha, pesando 4,03 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Foi apresentado o seguinte rol de testemunhas: PM Fernando Henrique Milanez (fl. 7) e PM Alex Fernando Cardoso Lopes (fl. 8).

Foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 58/62).

O acusado foi notificado (fl. 105), citado pessoalmente (fl. 156) e apresentou defesa prévia (fls. 113/114), por defensora nomeada (fl. 106), negando a prática do delito e pedindo absolvição, sem arrolar testemunhas.

Recebida a denúncia (fls. 120/122), foi realizada audiência de instrução.

As partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público pediu a

condenação nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A autoria e materialidade dos fatos restaram indiciariamente demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 3/6), termos de declarações, depoimentos e interrogatório (fls. 7/10 e 90), auto de apreensão e entrega (fls. 12/13), fotografias (fls. 38/39), relatórios (fls. 101/103 e 159) e laudos periciais (fls. 42/45 e 116/118).

Por sua vez, o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório dá respaldo à acusação.

Conforme a denúncia:

Segundo se apurou, em circunstâncias que serão aclaradas na instrução criminal, o denunciado obteve a substância ilícita acima mencionada e passou a comercializá-la. Na data dos fatos, WILLIAM PEIXOTO DA SILVA seguia na condução de sua bicicleta pelo contrafluxo da via pública acima referida e, ao avistar a viatura policial, em atitude suspeita, consistente em acelerar a bicicleta na tentativa de fuga, porém, foi abordado.

Em revista pessoal, no bolso da blusa de frio do denunciado, foram localizados e apreendidos 18 invólucros do entorpecente cocaína, na forma de crack, pesando 3,19 gramas; e 03 invólucros contendo maconha, pesando 4,03 gramas; prontamente embalados para o comércio, R\$ 2,70 em moedas e um canivete.

Em busca realizada na mochila do denunciado foram localizados diversos itens de limpeza doméstica e um alicate. Indagado sobre a origem dos produtos, informou que havia comprado no supermercado Atacadão em São José do Rio Preto. Acrescentado que, a bicicleta pegou emprestada do seu padrasto. Auto de exibição e apreensão acostado às 12/13.

A quantidade, o modo de acondicionamento da droga apreendida, bem assim as condições em que foram localizadas e apreendidas revelam o inequívoco intuito de tráfico de drogas pelo denunciado.

Laudo de constatação (fls. 42/45), detectou nos 03 invólucros contendo maconha, pesando 4,03 gramas a substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); nos 18 invólucros contendo cocaína, na forma de crack, pesando 3,19 gramas constatou-se a presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

Foram apreendidos: uma bicicleta azul da marca Bremem; um alicate com o cabo na cor laranja; 2 pacotes de sacos para lixo, sendo um que contém 10 unidades e outro 8 unidades; um canivete; um pacote de rejuntamento flexível extrafino de 1kg; a quantia de R\$ 2,70 em moedas; 1 shampoo Yabae de 500ml, 1 shampoo Salon Line de 300ml, um Shower gel 3 em 1 Boticário, de 205g; 640g de ração em uma sacola plástica; 750 ml de cera perfumada Rouxinol verde, 750 ml de cera perfumada Rouxinol vermelha, dois frascos de Veja Gold multiuso de 500ml cada, 800g de lava roupas em pó Ápyce, 4kg sabão em pó Omo, 1 caixa de 1,6kg de lava roupas concentrado Tixan Ypê (caixa aberta, com parte do produto usada); 2 caixas de cerveja Skol Beats com 8 unidades cada; 7,02g de maconha acondicionadas em 3 trouxinhas de papel e 8,4g de crack acondicionados em 18 pedras.

O laudo de exame químico-toxicológico apontou resultado positivo para:

1- tetrahidrocannabinol - THC nas amostras colhidas de 03 invólucros plásticos, de cor preta, fechados por aquecimento encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos com massa líquida de 4,03 grama(s).

2- cocaína nas amostras colhidas de 18 invólucros plásticos, de cor branca, fechados por aquecimento encerrando porção de material sólido petrificado de cor bege com massa líquida de 3,19 grama(s).

A testemunha PM Fernando Henrique Milanez narrou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento no bairro da ocorrência para coibir a prática de tráfico e furtos quando viu uma bicicleta no contrafluxo conduzida pelo acusado, que já é conhecido

nos meios policiais pela prática de tráfico e furto. Disse que, ao ser avistado pelos policiais, o acusado acelerou a bicicleta e só foi abordado a cerca de 800 metros. Na busca pessoal, encontraram droga na blusa do acusado, no bolso, e dinheiro. Na bicicleta, havia também uma bolsa, dentro da qual encontraram produtos de higiene e um alicate. Indagado, o acusado disse que comprou os itens no supermercado e que a droga não era sua, e nada disse sobre a bicicleta. Relatou que, diante disso, deram voz de prisão ao acusado e o conduziram ao plantão policial. Questionado pela Defesa, disse que, quanto ao dinheiro encontrado, foram moedas; não se recorda da quantia, mas acredita que era pouco dinheiro. Relatou não saber que o acusado é usuário de entorpecentes e disse que não o viu comercializando drogas nesse dia.

A testemunha PM Alex Fernando Cardoso Lopes afirmou que nessa noite estavam em serviço de patrulhamento quando avistaram o acusado no contrafluxo da via, de bicicleta e com uma mochila amarrada na garupa. Ao avistar a viatura, o acusado acelerou a pedalada. Na abordagem, durante a busca pessoal, foram encontradas, na blusa de frio que ele usava, algumas pedras de crack e umas porções de maconha, cerca de 2 reais e alguns centavos e um canivete. Na mochila, foram encontrado alguns itens de limpeza doméstica. Relatou que, quanto à droga, o acusado negou sua propriedade, e, quantos aos itens de limpeza, disse que os adquiriu no Atacadão, em São José do Rio Preto. O acusado não disse nada a respeito da bicicleta. Como ele já era conhecido dos meios policiais, deram voz de prisão ao acusado e o encaminharam à polícia civil. Questionado pela Defesa, disse não saber informar se o acusado é ou não usuário de entorpecentes e que, no dia dos fatos, não viu o acusado comercializando droga nem repassando a terceiros.

Em seu interrogatório, o acusado negou a acusação, afirmando que estava trabalhando, às 17h, em seu serviço, e seu patrão chegou com uma cerveja. Ao sair de seu emprego, depois de ter bebido um pouco, chegou em casa, pegou alguns produtos de limpeza, seu tênis e foi para a biqueira. Chegando lá, apresentou seu tênis e os produtos de limpeza; o pessoal da biqueira não quis os produtos, apenas o tênis, então o acusado trocou seu tênis por drogas. Disse que as drogas não eram para ele vender, e sim para utilizar em casa. O alicate que estava dentro da bolsa era do seu serviço. Quando chegou em casa, depois do trabalho, tirou somente a marmitta de dentro da bolsa e colocou os produtos de limpeza. Disse que não sustenta seu vício com a venda de drogas, e sim com seu trabalho. Disse que sabe que não pode beber, porque faz tratamento para superar o vício, mas que nesse dia teve uma recaída.

Diante das narrativas oferecidas, concluo que o delito está efetivamente caracterizado, essencialmente, pelos fundamentos abaixo.

Em patrulhamento visando combater o tráfico e furto que estava acontecendo na cidade, os policiais avistaram o acusado, que já era conhecido nos meios policiais, em um bicicleta com uma mochila na garupa. Ao notar a viatura, o indivíduo tentou acelerar a bicicleta, buscando se evadir da abordagem, mas os policiais o alcançaram e fizeram a revista pessoal.

Foram encontrados, no bolso da blusa de frio do acusado, 18 invólucros de crack e 3 porções de maconha, todos embalados para comércio, além de um canivete e a quantia de R\$ 2,70 em moedas. Em sua mochila, ainda foram encontrados diversos itens de higiene e limpeza e um alicate. Na delegacia, o acusado disse que tais itens eram seus, foram comprados no Atacadão, em São José do Rio Preto, e que os levaria até sua irmã; em juízo, disse que, ao sair de seu serviço, onde tinha bebido um pouco, pegou os itens em sua casa, além de um tênis, e foi até a biqueira para trocá-los por droga para seu próprio consumo.

Pela quantidade, variedade e modo de acondicionamento das drogas, não é possível afirmar de plano que elas se destinavam a consumo pessoal (art. 28, §2º, da Lei 11.343/06). Além disso, a apreensão de quantia em dinheiro, somadas à atitude do acusado ao ser abordado pelos policiais corroboram a existência do tráfico.

Vale dizer ainda que o simples fato de as testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer seus depoimentos, os quais devem ser valorados com isenção e em cotejo com os demais elementos probatórios:

Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares

responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Sequer há motivo para se imaginar que os agentes pretendessem incriminar o acusado falsamente. Por sua vez, a Defesa não conseguiu demonstrar a falibilidade dos depoimentos das testemunhas. Com efeito, não basta apenas argumentar que inexiste presunção de veracidade dos depoimentos dos policiais. É preciso ir além das teses, oferecendo-se explicação concreta para os fatos. A versão apresentada pelo acusado precisaria ser verossímil e não foi. Na verdade, a tese de Defesa pressupõe que a conduta dos agentes assumiu conotação abusiva ou que alguém queria prejudicá-lo, mas não há razão concreta e idônea que a sustente, pelos motivos já expostos.

Ressalte-se também que nada impede que a traficância ocorra em paralelo com o uso de drogas e/ou com o exercício de ocupação lícita, razão pela qual tais alegações não afastam a caracterização da conduta típica. Ademais, o art. 33, caput, da Lei 11.343/06 se caracteriza como tipo misto alternativo, de maneira que basta que o agente incorra em qualquer das condutas ali mencionadas, dentre elas a de ter drogas em depósito, sem autorização, como descrito na denúncia.

Logo, a conduta não está acobertada por causa excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, restando bem caracterizada a prática do delito.

Por tais motivos, a pretensão punitiva procede.

Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59, caput).

Ademais, no tocante especificamente aos crimes previstos na Lei 11.343/06, vale lembrar que “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (art. 42).

Prevalece na jurisprudência que, por serem circunstâncias preponderantes e devido à vedação ao bis in idem, a natureza e a quantidade de entorpecente devem ser valoradas apenas na primeira fase da dosimetria e só podem ser usadas na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado se estiverem conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, que, unidas, caracterizem a dedicação do agente a atividades criminosas ou integração a organização criminosa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. O tratamento legal conferido ao crime de tráfico de drogas traz peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

3. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

4. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena.

5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

6. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores "natureza e quantidade de drogas apreendidas" para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

7. A natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 687.767/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intollerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça

o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença. (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

O delito de tráfico de drogas é punido com pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto e a de detenção, em regime semiaberto ou aberto, conforme o montante aplicado (menor que 4 anos, maior que 4 anos e menor que 8 anos ou maior que 8 anos) e a presença ou não de reincidência e antecedentes (art. 33, caput e §2º, do CP, Súmulas 269 e 440 do STJ e Súmulas 718 e 719 do STF).

A pena de multa é calculada em dias-multa, sendo, no mínimo, de 10 e no máximo de 360 dias-multa (art. 49 do CP), segundo o critério trifásico previsto no art. 68 do CP.

O valor do dia-multa não pode ser inferior a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser considerada a situação econômica do réu (art. 60 do CP).

Na primeira fase, quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui condenações transitadas em julgado para a Defesa em 30/01/2022 (data do fato: 30/08/2021) e 22/01/2016 (data do fato: 10/04/2013) (fls. 147/150).

Conforme o entendimento jurisprudencial, as condenações por fatos posteriores ao descrito na denúncia não caracterizam antecedentes e condenações antigas podem ser valoradas negativamente porque os antecedentes não se sujeitam ao prazo depurador de 5 anos aplicável à reincidência (art. 64, I, do CP)

A jurisprudência atual desta Corte, sedimentada no Enunciado de Súmula 444, veda às instâncias inferiores valorar negativamente a pena-base em função de inquéritos ou processos em curso, sem trânsito em julgado, em respeito ao princípio da presunção de não culpa. Ainda, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente. Entrementes, plenamente viável que a condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a ela, seja utilizada como circunstância judicial negativa. (HC 443.678/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019)

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. (HC 433.543/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-

se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)

Assim, a primeira condenação mencionada, em negrito, deve ser utilizada para caracterizar a reincidência, que é circunstância agravante, a ser valorada na segunda fase (Súmula 241 do STJ), enquanto a outra deve ser valorada negativamente como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto às demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade do ato praticado; conduta social e personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e comportamento da vítima), não devem ser valoradas negativamente, pois inexistem peculiaridades fáticas aptas a justificar a exasperação da pena-base.

Conforme a jurisprudência, em regra, é razoável exasperar a pena-base em 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente, porém, é possível aplicar fração superior para a valoração de um único vetor, se preponderante:

4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). (AgRg no HC 666.280/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Assim, pela presença de antecedentes, mostra-se proporcional ao caso concreto exasperar a pena em 1/6, o que resulta em: 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), pelo antecedente mencionado, motivo pelo qual a pena deve ser exasperada em 1/6, o que resulta em: 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Nesse sentido, a reincidência afasta a caracterização do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

Logo, torno definitiva a pena em: 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

Pela reincidência, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §2º, a, do Código Penal).

Deixo de considerar o tempo de prisão preventiva para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, por entender que tal avaliação compete ao juízo da execução criminal, haja vista que para a progressão de regime é necessária a presença da boa conduta carcerária (art. 112, §1º, da Lei 7.210/84), requisito subjetivo que, por isonomia, deve ser exigido de todos, sentenciados e presos provisórios (art. 387, §2º, do CPP).

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem à suspensão condicional da pena, uma vez que embora o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, é reincidente, possui antecedentes e a

pena é maior que 4 anos, de modo que a concessão dos benefícios não seria suficiente ou socialmente recomendável (arts. 44, 59 e 77 do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar WILLIAM PEIXOTO DA SILVA à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Por não mais interessar ao processo, autorizo a destruição do entorpecente apreendido (art. 72 da Lei 11.343/06 e art. 524-A das NSCGJ). Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico (art. 524-A, §2º, das NSCGJ). Serve a presente como ofício.

Como efeito da condenação, imponho a perda dos bens e valores apreendidos (arts. 5º, LIV, e 243, parágrafo único, da Constituição e art. 91 do CP). Os bens poderão ser destinados à conservação e utilização, se houver interesse público, ou à alienação, enquanto o produto da arrematação e valores apreendidos deverão ser mantidos em depósito até o trânsito em julgado (arts. 61 a 63 da Lei 11.343/06). Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico. Serve a presente como ofício.

Custas pelo réu, observada a gratuidade de justiça.

O acusado responde ao processo preso preventivamente após ser surpreendido em flagrante e a necessidade de custódia cautelar permanece em virtude da gravidade concreta da conduta, devido à reincidência, à expressiva quantidade e variedade de drogas encontradas e à caracterização do tráfico como meio de vida e de sustento do uso de drogas, contexto que evidencia que a prisão é necessária para evitar a reiteração da prática delitiva, mostrando-se ineficaz medida cautelar diversa, inclusive pela possibilidade de prática de tráfico em domicílio (arts. 282, §6º, e 312 do CPP).

Por tais motivos, recomende-se o acusado à prisão em que se encontra (art. 387, §2º, do CPP). Serve a presente como ofício.

Expeça-se a guia de recolhimento provisória.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 15, III, da Constituição e art. 398 das NSCGJ) e a guia de recolhimento definitiva (art. 467 a 474 das NSCGJ); bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

Expedida a guia, ela deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução mediante lançamento da movimentação "processo findo", com a situação "suspensão" (art. 468, §3º, das NSCGJ), certificando-se nos autos.

Após, nada mais restando a deliberar, archive-se, fazendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado (art. 184 das NSCGJ).

Intime-se.

José Bonifacio, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA